

1502441-95.2021.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cássio Henrique Dolce de Faria

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... anterior transitada em julgado por tráfico privilegiado, como se vê da certidão alusiva ao processo de conhecimento n.º 1500060-85.2019.8.26.0630 (certidão a fls. 67). É questão polêmica em jurisprudência se a condenação pretérita por tráfico privilegiado gera reincidência específica, no caso de nova condenação por tráfico. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Jd. Panambi, Santa Bárbara d'Oeste - 13450-515 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo n.º:

1502441-95.2021.8.26.0533

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237716/2021 - DISE-DEL.SEC.AMERICANA, 19974480 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 61/21/371 - DISE-DEL.SEC.AMERICANA, 2237716 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CARIA GONCALVES DE ASSIS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Aos 07 de janeiro de 2022, às 14:30h, em audiência realizada por videoconferência pela 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste, Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. CASSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA, comigo, escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual o representante do Ministério Público Dr. Rodrigo Aparecido Tiago, o acusado e a defensora Dra. Solange Naidelice Rodrigues OAB 125082/SP, todos devidamente intimados e após responderem de forma positiva ao convite enviado pelo programa Microsoft Teams. Em seguida, foi concedida entrevista privada entre o acusado e sua advogada por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Como primeiro ato, todos os integrantes exibiram documento de identificação pessoal com foto. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. 1) Tendo em vista o disposto no Decreto n.º 8.858/16 e na Súmula Vinculante n.º 11, do Supremo Tribunal Federal, justifico que houve manutenção das algemas para a garantia da integridade física de todos os participantes da audiência, principalmente das pessoas que se encontram na sala de videoconferências

do centro de detenção provisória em questão, vez que a segurança daquele local é realizada por reduzido número de agentes. Nesse sentido: "a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11, do STF - que dispõe que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito - não obsta o seu emprego se demonstrados os riscos nela previstos" (STJ, RHC: 39729 SP 2013/0241579-3, relator ministro Moura Ribeiro, julgado em 3 de setembro de 2013). 2) Esta audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, na forma do Comunicado C.G. n.º 284/2020, diante da pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do fórum local, sendo que as gravações serão disponibilizadas em certidão que será juntada nos autos posteriormente". A seguir, procedeu-se à oitiva de uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como ao interrogatório do réu, conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão disponibilizadas em certidão nos autos. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. Declaro encerrada a fase de instrução processual". Depois disso, passou-se aos debates orais em audiência, ainda conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência, sendo que pelo Ministério Público, os principais pedidos foram: a procedência da pretensão inicial, com exasperação da pena-base, reconhecimento da birreincidência específica e da causa de aumento de pena alusiva ao envolvimento de adolescente na mercancia, fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal e vedação à substituição, enquanto que pela defesa, os principais pedidos foram: a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a do artigo 28, da Lei de Drogas. Na sequência, o MM. Juiz proferiu a sentença nos seguintes termos: "Vistos, etc. GABRIEL CARIA GONÇALVES DE ASSIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06. E isso porque, segundo consta da denúncia de fls. 1/3, no dia 31 de agosto de 2021, por volta de 12h00min, na Avenida Ruth Garrido Roque, n.º 1.190, bloco 2, Parque do Lago, nesta cidade e comarca, ele, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o menor E.D.O.L., de dezessete anos, guardava, para fins de comercialização, oitenta e cinco porções de cocaína, dezenove pedras de crack e cento e trinta e cinco porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado (fls. 137) e apresentou defesa prévia (fls. 141/142). Recebida a denúncia (fls.143/144), o réu foi citado (fls. 173). Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, tendo sido o acusado interrogado, em seguida. Encerrada a instrução, em debates: a) o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão inicial, com exasperação da pena-base, reconhecimento da birreincidência específica e da causa de aumento de pena alusiva ao envolvimento de adolescente na mercancia, fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal e vedação à substituição; b) a defesa do acusado postulou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a do artigo 28, da Lei de Drogas. É o relatório. Fundamento e decido. Não há matéria preliminar pendente de apreciação. No mérito, a pretensão inicial procede, pelos fundamentos expostos a seguir. A materialidade delitiva do crime encontra-se provada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 15/19, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, pelo laudo de constatação de fls. 23/26 e, finalmente, pelo exame químico-toxicológico de fls. 100/103. Há, também, prova suficiente da autoria. Na polícia (fls. 14), o acusado negou a prática delitiva. Disse que estava em um bilhar no fundo do Condomínio Manacá (no qual sua irmã reside) quando os policiais o detiveram, acusando-o de traficar drogas, o que não procede. Salientou que não portava nenhuma droga e que o dinheiro que trazia consigo era fruto de seu trabalho. Finalizou, dizendo que o adolescente também detido por tráfico é seu conhecido do condomínio e que não é proprietário e nem teria andado em veículo VW/Gol, de cor branca. Em juízo, ele novamente negou a imputação. Disse que se dirigiu ao local para comprar maconha de um indivíduo

chamado Elton. Deu-lhe R\$ 50,00. Fumou o cigarro de maconha na companhia de um amigo e ficou aguardando receber o troco num bar ao qual se dirigiu e no qual permaneceu, jogando bilhar. Então, o adolescente veio e lhe deu este troco (R\$ 45,00). Logo depois disso, os policiais civis adentraram o local e detiveram-no, junto com o adolescente. A tese de autodefesa, no entanto, não pode ser acolhida, porque isolada no conjunto probatório. De início, deve-se ressaltar que pesa em desfavor do acusado a situação comprometedora derivada de sua captura em flagrante de delito, na posse de dinheiro e guardando expressiva quantidade de entorpecentes diversos. Ademais, os policiais civis Emerson e Adriano, em relatos coerentes em sua essência, confirmaram, na delegacia (fls. 7/12) e em juízo, que receberam denúncia anônima relatando a existência de um ponto de tráfico de drogas no interior do condomínio Manacá. Sendo assim, duas equipes foram designadas para averiguar o teor da denúncia, em viaturas descaracterizadas. Pelo local, montaram um posto de observação e constataram que um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o réu, embarcou como passageiro em um automóvel Gol de cor branca. Poucos minutos depois, o veículo retornou ao condomínio e lá deixou o réu, que retornou portando uma sacola cinza. A seguir, ele entrou no condomínio e foi até as caixas de energia do bloco B, onde guardou esta sacola cinza. Do interior da sacola retirou um pacote e o entregou a outro indivíduo, o qual estava sentado próximo a uma instalação de gás. Posteriormente, este segundo indivíduo foi identificado como o adolescente infrator E.D.O.L. Logo em seguida, o réu se dirigiu para um bar próximo, o qual possui um alambrado que permite acesso ao condomínio. Observaram, ainda, que o adolescente realizou dois atendimentos similares aos comumente vistos em comercialização em locais de tráfico de drogas. Decidiram, então, abordar os indivíduos. Dirigiram-se primeiramente ao réu, que estava no lado externo do bar, jogando bilhar. Depois disso, a equipe se dividiu e realizou a abordagem do adolescente E.D.O.L., que estava no interior do condomínio. Ao perceber que se tratava de investigadores de polícia, E.D.O.L. tentou se evadir e jogou as drogas para cima, depois de tirá-las de seu bolso. Contudo, foi alcançado e detido. Então, foram recuperadas seis porções de maconha, correspondentes às drogas que o menor havia jogado para o alto. Com o réu foram encontrados R\$ 115,00 e, no local em que ele havia escondido a sacola de cor cinza, no interior dela, foram localizados oitenta e cinco pinos de cocaína, trinta e quatro vidros contendo maconha, dezenove pedras de crack, noventa e três buchas de maconha (idênticas às que foram lançadas para o alto por E.D.O.L.) e mais dois saquinhos do tipo "zip-loc" contendo maconha. Indagado, o réu negou a prática do delito de tráfico. Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao réu e apreendido o menor, sendo ambos apresentados, com as substâncias e valores, na unidade policial. Não há motivo algum para que seja negada credibilidade aos relatos dos policiais civis, com quem o réu não demonstrou a existência de nenhuma animosidade. Tais relatos, quando harmônicos entre si e com o restante do conjunto probatório, são suficientes para fundamentar a sentença condenatória, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vide, a propósito, o decidido no Habeas Corpus n.º 395.325/SP, pela Quinta Turma daquela Corte, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 18 de maio de 2017. Pequenas contradições, referentes a aspectos periféricos da conduta, são inerentes ao psiquismo humano. Não têm o condão de minar a credibilidade do declarado pelas testemunhas, até mesmo porque não é crível a suposição de que agentes públicos que também têm por dever funcional a manutenção da lei e da ordem viriam a juízo mentir (respondendo inclusive penalmente por sua conduta) para incriminar terceiro desconhecido. Diante desse conjunto, não há como prevalecer a tese de autodefesa, já que há prova suficiente a confirmar a versão acusatória. Inviável, destarte, a absolvição por falta de provas ou mesmo a desclassificação da conduta para uso, pois o contexto evidencia que o réu praticava mercancia das substâncias no local em que veio a ser preso, na companhia do adolescente E.D.O.L., o que também justifica a incidência da respectiva causa de aumento articulada na denúncia. Por consequência, impõe-se a condenação. Passo, agora, à fixação da pena, em atenção aos vetores do artigo 42, da Lei de Drogas. A pena-base deve ser fixada acima do piso legal, ante a expressiva variedade e quantidade de drogas encontradas com o acusado e seu comparsa inimputável (massas líquidas de 17,1 gramas de cocaína

+ 188,5 gramas de maconha + 4 gramas de maconha + 2,4 gramas de crack, distribuídas em oitenta e cinco porções de cocaína, cento e uma porções de maconha, dezenove porções de crack - fls. 100/103), muito superior à média encontrada em poder de iniciantes. Estas circunstâncias não podem ser desconsideradas, até porque sinalizam, a quem queira enxergar, maior envolvimento do réu com a mercancia ilícita de entorpecentes. Ademais, como o réu tem contra si duas condenações pretéritas transitadas em julgado, uso uma delas, extraída do processo de conhecimento n.º 0002601-05.2018.8.26.0533 (certidão a fls. 66/67 - condenação por tráfico privilegiado), como mau antecedente. Saliento que esta condenação não será considerada para fins de reincidência, de modo que esta decisão respeita e se mostra de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula n.º 241, do Superior Tribunal de Justiça. Por tudo isso, fixo a pena-base um quinto acima do mínimo, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, o réu registra outra condenação anterior transitada em julgado por tráfico privilegiado, como se vê da certidão alusiva ao processo de conhecimento n.º 1500060-85.2019.8.26.0630 (certidão a fls. 67). É questão polêmica em jurisprudência se a condenação pretérita por tráfico privilegiado gera reincidência específica, no caso de nova condenação por tráfico. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não, porque os crimes têm natureza distinta: Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 604.376/SP, Sexta Turma, relator ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 17 de setembro de 2020; Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 592.398/SP, Quinta Turma, relator ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 20 de outubro de 2020. Este entendimento, a que se deve atribuir eficácia persuasiva, deve ser prestigiado. Por isso, e em revisão a posição anterior deste magistrado, o réu será considerado, para todos os fins e efeitos de direito, reincidente genérico, do que deriva o aumento de um sexto nas penas anteriormente cominadas, a totalizar: sete anos de reclusão e setecentos dias-multa. Não há atenuantes (réu já maior de vinte e um anos na data dos fatos e não confesso). Na terceira fase, há o aumento previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que o acusado praticava a mercancia na companhia de comparsa adolescente, fato devidamente comprovado nos autos. Disso deriva o acréscimo de um sexto nas penas até aqui cominadas, o que importa em oito anos e dois meses de reclusão e oitocentos e dezesseis dias-multa. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu sinalizam sua intimidade com o mundo do crime, de modo que não lhe é aplicável a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. São penas finais do réu, portanto: oito anos e dois meses de reclusão e oitocentos e dezesseis dias-multa. Fixo regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, em razão da quantidade de pena a final cominada e também por ser o único compatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado. A quantidade de pena final cominada impede a substituição da sanção corporal, ou mesmo a concessão de sursis. Valor unitário do dia-multa no piso legal. Desnecessárias outras observações. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL veiculada por meio desta AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para condenar o réu GABRIEL CARIA GONÇALVES DE ASSIS, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06. Como consectário disso, aplico-lhe as penas de: a) oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa, de valor unitário mínimo. Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual n.º 11.608/03. Contudo, defiro ao acusado os benefícios da justiça gratuita, diante daquilo por ele relatado em seu interrogatório. Anote-se, ficando a exigibilidade da taxa judiciária sujeita ao sistema do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. O réu respondeu preso a todo o processo, com os requisitos e fundamentos que motivaram a sua segregação cautelar apenas se reforçando neste momento. Denego-lhe, em consequência, o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se esta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral; b) expeça-se guia de execução definitiva; c) expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado; d) autorizo a

destruição de eventual remanescente das substâncias apreendidas; e) expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas da quantia apreendida em poder do réu. Decreto o perdimento desta quantia ao já aludido Fundo, com fundamento no artigo 63, I, da Lei de Drogas, por considerá-la vinculada à prática delitativa. Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Dispensado registro (Comunicado n.º 27/2016). Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.", saindo as partes intimadas. Em seguida, foi renovado o direito de entrevista privada entre o réu e sua advogada por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Pela defesa e pelo sentenciado foi dito haver interesse em recorrer. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. Recebo o recurso interposto pela defesa nesta data, saindo a defensora intimada para oferecer as razões no prazo legal, independente de nova intimação. Após, abra-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões. Processado regularmente o recurso, cumpra-se o disposto nos Provimentos n.º 07/2007 e n.º 08/2011, remetendo-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens. Anote-se. Expeça-se guia de recolhimento provisória em nome do réu, remetendo-a regularmente instruída à Vara das Execuções Criminais competente". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do artigo 25, caput, da Resolução n.º 185/13, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Os presentes saem intimados. Nada mais. Eu, Douglas Beraldo, digitei.

MM. Juiz: (assinado digitalmente).